

次の【事例】中の実況見分調書につき、その証拠調べ請求に関して述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。

【事例】

司法警察員Kは、現住建造物に対する放火事件の捜査として、焼損した建造物につき、その所有者Vを立会人とする見分を行い、実況見分調書を作成した（実況見分調書には、Vの署名・押印のいずれもない）。Vが実況見分の際に建造物の特定の箇所を指し示しながら、Kに対し「ここにAが火を付けるのを見た。」旨説明したので、Kは、その箇所を写真撮影した後、同写真を実況見分調書に添付するとともに、Vの前記説明内容を実況見分調書に記載した。その後、Aが同事件の犯人として起訴された。検察官は、当該被告事件の公判前整理手続において、「建造物の焼損状況」を立証趣旨として実況見分調書の証拠調べを請求した。弁護人は、「Aは犯人ではなく、本件火災はVによる失火が原因である。」旨主張した上、実況見分調書について不同意の意見を述べた。

【記述】

- ア. 弁護人は、裁判長から、不同意意見の理由として実況見分調書が真正に作成されたものであることを争う趣旨であるかについて釈明を求められた場合には、釈明する義務を負う。
- イ. 実況見分調書につき、関連性があるとして証拠能力が認められるためには、Aが犯人であることを疎明する必要がある。
- ウ. Kが火災原因の調査、判定に関して学識経験を有しない場合には、実況見分調書が真正に作成されたものであるとは認められない。
- エ. 実況見分調書の証拠能力が認められるためには、K及びV両名に対する証人尋問が必要である。
- オ. 裁判所は、実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても、実況見分調書におけるVの前記説明内容が記載された部分を、Aが犯人であることを証明する証拠として用いることはできない。

No274	実況見分調書						正答率
予備H27-20	正解	ア 1	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 1	38%

ア 正しい

規則 208 条 1 項は、「裁判長は、必要と認めるときは、訴訟関係人に対し、釈明を求め、又は立証を促すことができる。」旨規定しているところ、釈明を受けた相手方は釈明に応ずる義務を負う。釈明権の行使は、裁判長の訴訟指揮権（294 条）の内容の一つを構成するところ、訴訟指揮が、訴訟の審理に一定の秩序を与え、判決に到達するための裁判所の合目的的活動とされていることからすれば、その訴訟の当事者等訴訟関係人が裁判長（裁判所）の訴訟指揮に従わなければならないことは当然だからである。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

証拠能力という関連性とは、証拠が要証事実の存否の証明に役立ち得る性質（証拠としての有意性）をいい、このような関連性のない証拠は証拠能力が否定される。そして、証拠の要証事実、一義的には、当事者が示す立証趣旨（証拠と証明すべき事実との関係、規則 189 条 1 項）に沿って把握される。本事例における立証趣旨は「建造物の焼損状況」であり、「A が犯人であること」は本件実況見分調書の立証趣旨にかかわらない事実である。よって、本件実況見分調書につき、関連性があるとして証拠能力が認められるためには、A が犯人であることを疎明する必要はない。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

実況見分調書とは、捜査機関（検察官、検察事務官又は司法警察職員）が任意処分として行う検証の結果を記載した書面をいい、321 条 3 項の「検証の結果を記載した書面」に含まれる（最判昭 35.9.8、百選 A38 事件）。また、検証とは、場所、物、人について、五官の作用により、その形状を感知する処分をいい、専門性を有する特別の知識経験のある者だけが認識し得る法則又は事実の供述である鑑定と異なり、その主体には専門性を有する特別の知識経験が要求されない。よって、K が火災原因の調査、判定に関し学識経験を有しているか否かは、実況見分調書が真正に作成されたものであるか否かとは関係を有しない。したがって、本記述は誤っている。なお、321 条 3 項にいう真正に作成されたものとは、通常、間違いなく自己が作成したということ（作成名義の真正）と相当な方法により真摯に見分し、その結果を正しく記載したことということ（記載内容の真正）をいう。

エ 誤っている

実況見分調書は、321 条 3 項の「検証の結果を記載した書面」に含まれる（最判昭 35.9.8、百選 A38 事件）。そして、同条項は「検察官、検察事務官又は司法警察職員の検証の結果を記載した書面は、その供述者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、第 1 項の規定にかかわらず、これを証拠とすることができる。」と規定しているので、実況見分調書は、実況見分を行い調書を作成した者が、公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときに限り、証拠能力が認められる。本件実況見分調書の作成者は司法警察員 K であり、これに証拠能力を認めるためには、K に対し証人尋問をする必要がある。他方、本件実況見分調書には立会人である V の指示説明が記載されているが、これは「建造物の焼損状況」という立証趣旨との関係において、V の指示説明が実況見分の動機、手段となっていることを示すものであり、「A が火をつけた」という内容の真実性を立証することを直接的な目的とした被疑者以外の者の供述として、これを録取するものではない（最判昭 36.5.26 参照）。よって、V の指示説明の記載は供述証拠ではなく、伝聞例外の規定（321 条 1 項 3 号等）の適用はない。よって、本件実況見分調書の証拠能力を認めるにつき、V を証人尋問する必要はない。したがって、本記

述は誤っている。

オ 正しい

本件実況見分調書におけるVの説明内容が記載された部分、すなわち、「ここにAが火をつけるのを見た。」という供述を、「Aが犯人であること」を証明する証拠として用いる場合、この供述は、Vがそのような指示、説明をしたという事実を示すためのもの（いわゆる現場指示）ではなく、供述の内容の真実性が問題となる、いわゆる現場供述に当たる。そうすると、本件実況見分調書におけるVの説明内容が記載された部分は、公判期日外の供述を内容とする証拠であって、公判期日外の供述の内容の真実性を立証するために提出される証拠であり、いわゆる伝聞証拠（320条1項）に当たる。よって、本件実況見分調書が真正に作成されたものであることが認められても、弁護人が不同意の意見を述べている（326条1項参照）。本記述では、Vの署名があり（321条1項柱書参照）、かつ321条1項3号（この調書は、司法警察員の面前における供述を録取した書面であり、「前2号に掲げる書面以外の書面」に当たる）の要件を満たさない限り、320条1項により、その証拠能力は否定される。したがって、本記述は正しい。

